

1501963-53.2021.8.26.0318

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FELIPE CAVASSO

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... ocasionais, mas sim de pessoas que se dedicavam ao narcotráfico e disseminação de drogas em massa nesta cidade. Não merecem o reconhecimento da minorante justamente porque não são aqueles chamados "pequenos" traficantes ou que se aventuraram pela primeira vez em empreitada delituosa desse tipo. Não fazem jus ao tráfico privilegiado.

Pena definitiva: 05 (cinco) anos de reclusão e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501963-53.2021.8.26.0318 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501963-53.2021.8.26.0318

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2324393/2021 - DEL.POL.LEME, 21669824 - DEL.POL.LEME, 6552/21/807 - DEL.POL.LEME, 2324393 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAMILA DE OLIVEIRA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz Substituto: FELIPE CAVASSO

Vistos.

CAMILA DE OLIVEIRA, LUCAS DE JESUS DA ROCHA e SAMUEL SOUZA FERREIRA foi(ram) denunciado(a)(s) como incurso(a)(s) no art. 33, caput, e no art. 35, ambos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 29 de novembro de 2021, por volta de 13h15min, na Rua Roldão Francisco Ferreira, 261, Jardim Saulo, nesta cidade e comarca de Leme/SP, preparavam, guardavam e tinham em depósito, para fins de tráfico, 581 porções de "cocaína", pesando 620 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Auto de Exibição e Apreensão de fls. 35/37 e Auto de Constatação Preliminar de fls. 38/39) e, em data anterior ao dia 29 de novembro de 2021, nesta cidade e comarca de Leme/SP, associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente, o crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

O(a)(s) acusado(a)(s) foram notificado(a)(s) e apresentaram defesa prévia. A denúncia foi recebida, não sendo absolvidos sumariamente e inaugurando-se a instrução criminal, ao longo da qual ouviram-se as testemunhas, interrogando-se os acusados ao final.

As partes manifestaram-se em debates, pugnando o Ministério Público pela condenação, e a(s) Defesa(s) requereu a absolvição por falta de provas, declaração de nulidades das provas produzidas ou aplicação da pena em seu patamar mínimo, com os consectários legais.

É o relatório. Fundamento e decido.

Procede em parte a pretensão punitiva.

A materialidade está comprovada pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 317/319), auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 21/25), auto de exibição e apreensão (fls. 35/37), auto de constatação preliminar (fls. 38/39), fotografias (fls. 60/68), comprovante de depósito judicial (fls. 174), laudo pericial (fls. 312/316), bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria, em relação ao crime de tráfico de drogas, é certa.

Os policiais militares Gabriel Conti da Silva e Fabricio Doniseti dos Santos, em resumo, relataram que na data dos fatos receberam uma denúncia de um indivíduo que não quis se identificar, informando que no local dos fatos, em uma residência de uma pessoa chamada Camila, era efetuado preparo de drogas, e que tais drogas eram do réu Samuel, este já conhecido nos meios policiais por envolvimento com o tráfico de drogas. Foram ao local e bateram no portão da residência. Camila demorou para atender a equipe. Escutaram um barulho de telhas se quebrando e observaram que o réu Samuel estava no telhado. Camila abriu o portão e fez contato com a equipe. Nesse momento, o policial Fabricio deu ordem de parada ao réu Samuel, sendo que este desobedeceu e continuou a empreender fuga pulando para outros telhados. Diante de tal situação, foi solicitado o apoio de outras guarnições para capturar o réu Samuel. Posteriormente, informaram a ré Camila das denúncias recebidas, tendo a ré autorizado a entrada da equipe na residência. Durante a busca pela residência, foi realizada a abordagem do réu Lucas, que estava em uma sala. Encontraram um pote de cocaína a granel, um liquidificador com resquícios de cocaína, 580 eppendorffs cheios de cocaína, alguns eppendorffs vazios, uma balança de precisão e dois pratos com resquício de cocaína. O réu Samuel foi abordado em outra residência, que havia entrado para se esconder. Ainda no local dos fatos, ao serem indagados sobre as drogas encontradas, a ré Camila confessou que estava preparando as drogas para comercialização. O réu Lucas também confessou sua participação, tendo o réu Samuel permanecido em silêncio. Posteriormente o réu Lucas disse que seus documentos estavam na sua casa e que no local tinha mais entorpecentes bem como um valor em dinheiro de propriedade do réu Samuel. Outra equipe foi até a residência do réu Lucas, foram recebidos por Nicole a qual autorizou a entrada dos policiais. No interior do imóvel, a equipe encontrou a quantia de R\$ 2.475,00 escondido. Nicole disse aos policiais que arremessou uma caixa com drogas para fora da residência e confessou que o dinheiro e as drogas eram de propriedade do réu Samuel, contudo a equipe não encontrou a caixa que ela teria arremessado, mas a proprietária da residência, onde teriam caído a caixa com a droga, informou que Nicole realmente arremessou a caixa para o interior de sua casa, mas dois indivíduos pegou as drogas e saíram do local.

Os policiais disseram que foi filmada a autorização para entrada na residência, o que teria sido entregue à Polícia Civil.

O policial Fabrício Doniseti ainda acrescentou como se deu a busca e encontro do réu Samuel, o que se deu em outra casa, onde ele havia "rendido" um morador e dito que estaria fugindo da polícia. Descreveu que foi feita diligência na casa de Lucas, o qual informou que havia drogas e dinheiro proveniente do tráfico no local. Descreveu que a esposa ou companheira de Lucas havia jogado drogas na casa de uma vizinha. Esclareceu ter visualizado o réu Samuel em cima do muro.

Natalia de Oliveira Martins disse ser amiga do réu Lucas. Viu a viatura passar na rua. A viatura voltou de ré e parou na esquina. Quando saiu, já havia um policial no muro e outro no portão falando com Camila. Ela disse que ia pegar a chave, mas

logo os policiais pularam o muro. Foi para dentro da casa e ficou lá o tempo todo. Nunca soube de algum envolvimento de Lucas com atividades ilícitas. Pelo que viu, os policiais entraram sem autorização.

Interrogada, a ré Camila disse que o corréu Lucas chegou com uma mochila preta na sua casa. Ele pediu para que ela deixasse ele fazer as coisas na casa, por cem reais. Precisava do dinheiro e permitiu. Sabia que Lucas ia preparar a droga na casa. Samuel foi à sua casa para comprar energéticos. Gravou o vídeo a pedido dos policiais. Disse que ouviu batendo no portão. Foi atender e pediu para que esperassem para pegar chave. Logo um dos policiais pulou para dentro da casa. Conhecia Lucas há uns dois anos. Se deixou levar pela situação. Lucas não disse de quem ele pegou as drogas. Sobre o dinheiro encontrado na casa do Lucas nada sabe. Foi Lucas que começou e encher os pinos. Fazia cerca de 20 minutos que ele estava ali. Não autorizou os policiais entrarem na casa, mas se lembra de ter assinado alguns papeis, não sabia o que era. Assinou os documentos depois de entrarem. Viu quando os policiais filmaram ela autorizando a entrada e dizendo que a droga era de Samuel. Negou ter se associado aos demais réus para a prática de crimes.

Interrogado, o réu Samuel disse ter entrado na casa da Camila para beber água. Foi até o tanque para isso. Estava esperando. Não chegou a entrar na casa. Não viu nenhuma droga e não manipulou nada. Viu os policiais em cima do muro e olhando pelo portão. Quando viu que eles iriam entrar resolveu sair correndo por medo dos policiais, que sempre o ameaçavam na rua. Não sabia que no local havia droga. Nega participação no crime. Não se associou com os demais réus.

Interrogado, o réu Lucas disse que no dia dos fatos o réu Samuel passou na sua casa e lhe ofereceu dinheiro para que embalasse algumas drogas. Ele pediu ainda para guardar um dinheiro na sua casa. Foram à casa de Camila para fazer essa preparação. Logo os policiais chegaram. Disse que a droga era de Samuel. Contou também que havia um dinheiro na sua casa. Na sua casa não havia mais drogas. Foi a primeira vez que fizeram isso. No mesmo dia é que Samuel passou em sua casa e pediu para que fossem até a casa de Camila, que os ajudaria e embalar as drogas. Não sabe o que ela ganharia com isso. Os três réus estavam na casa e também embalava os entorpecentes. Disse que, em seu interrogatório na fase policial, foi coagido pelo advogado de Samuel, que disse que conseguiria soltá-los naquela oportunidade. A prova é segura para a condenação dos réus pela prática do crime de tráfico de drogas, o que se extrai dos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares.

É certo que, se comparados os depoimentos prestados em sede inquisitiva e judicial, sempre será possível verificar a existência de pequenas contradições, que se reputam naturais, porque a ninguém é dado prestar depoimentos estritamente idênticos, sem nenhuma diferença.

O que importa, no entanto, é a coerência no que é fundamental.

No caso, fundamental era a quantidade da droga, sua forma de acondicionamento, com quem foi encontrada e em que circunstâncias isso se deu. Cumpre consignar que nada há nos autos que indique intenção das testemunhas em incriminar indevidamente o acusado.

Além disso, acolher essa tese seria desmerecer o trabalho dos policiais em suas investigações.

Salvo comprovação em contrário, a atuação dos agentes públicos goza de presunção de veracidade e legitimidade. Sobre o tema, invoco famoso precedente da lavra do eminente Min. Celso de Mello: Prova – Depoimento testemunhal de agentes policiais – Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos (STF, 1ª T., HC nº 74.608-0/SP).

De outro lado, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, para determinar se a droga destinava-se ao consumo pessoal ou de terceiros, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Nessa medida, apreendeu-se significativa quantidade de droga, qual seja, 581 porções de cocaína, na casa onde estavam os três réus, os quais ali estavam para preparar esses entorpecentes, a fim de distribuí-los para entrega e consumo em massa nesta cidade.

Antes de mais nada, é preciso lembrar que o Código Penal adotou a teoria monista da ação no que tange à figura do concurso de pessoas. Veja-se a redação do artigo 29, caput, do Estatuto Repressivo: Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.

Nesses termos, tem-se que Samuel, ao perceber a presença da polícia, empreendeu fuga, inclusive pulando por diversos muros de outras casas. Lucas e Camila ficaram na residência, na qual estavam preparando vultosa quantidade de droga, que foi apreendida.

Samuel foi detido logo na sequência.

Na casa de Lucas havia também vultosa quantia em dinheiro, mais de R\$ 2.400,00, produto do narcotráfico. Camila e Lucas confessaram em juízo que estavam preparando drogas na casa.

Embora Camila tenha tentado dar uma versão exculpatória a Samuel, fato é que o corréu Lucas confirmou a participação dele na empreitada delituosa. Lucas, perante este Juízo, delatou o réu Samuel, como sendo a pessoa que organizou toda a ação ilícita, partindo dele a oferta a Lucas para que preparassem drogas na casa de Camila.

Essa versão é verdadeira, porque Samuel empreendeu fuga do local da apreensão tão logo percebeu a presença dos policiais, caindo por terra sua fantasiosa alegação de que estava ali na casa apenas para beber água ou comprar energéticos. Outrossim, a delação de Lucas encontra amparo na gravação realizada pelos policiais quando da ocorrência (vídeo de fl. 97). Ou seja, não se está a levar a palavra de Lucas, isoladamente, para formar um juízo de condenação em face de Samuel, mas todo o conjunto que foi coligido durante a instrução processual, além da análise do comportamento de Samuel no momento da ocorrência.

Dessa forma, verifica-se que a prova produzida, analisada em conjunto com os interrogatórios, é bem robusta a respeito da prática do crime de tráfico de drogas por parte dos três réus.

Não há nulidade ou prova ilícita em razão do ingresso no domicílio do(a) acusado(a) sem prévio mandado judicial.

O ingresso na residência de qualquer indivíduo, a despeito de sua natureza inviolável, é excepcionada em casos como o dos autos, onde haja a prática de crime e a consequente situação flagrancial, conforme expressamente prevê a Constituição em seu artigo 5º, inciso XI.

Isso porque, o delito de tráfico de entorpecentes possui natureza permanente, cuja ação se protraí no tempo, permitindo a prisão do agente enquanto se mantiver este estado.

Nesse cenário, a garantia fundamental do acusado deve ser flexibilizada em razão de não poder ser utilizada como escudo para a prática de atos ilícitos, em razão da aplicação da técnica de interpretação da cedência recíproca, uma vez colocados em confronto duas garantias de ordem constitucional: a inviolabilidade do domicílio do acusado e a proteção à segurança e saúde pública, bens jurídicos afetados por sua conduta.

O colendo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, assim decidiu a questão: Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral.

2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é

aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603616, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).

No caso em apreço, a situação anterior ao ingresso justificava a ação dos policiais.

Mas, ainda que assim não fosse, houve autorização gravada e escrita por parte da moradora (tanto da casa de Camila, quanto do corréu Lucas), conforme vídeo de fl. 97 e autorizações escritas de fls. 74/75.

E mesmo que fosse questionada a licitude da gravação e da autorização escrita, sobre a situação anterior ao ingresso, tem-se a existência de denúncia anônima acerca da preparação das drogas no local dos fatos.

Quando os policiais lá chegaram, foram atendidos pela moradora e houve autorização escrita e gravada.

Além disso, quando os agentes públicos ali estavam, o réu Samuel empreendeu fuga, subindo por telhados daquela e de outras casas. Ou seja, havia fundadas razões aptas a permitir que os policiais ingressassem na residência, porque é evidente que, havendo informações sobre prática de tráfico numa casa e, chegando ali os policiais, veem o suspeito fugindo por cima de telhados, é possível presumir que algo de ilícito ali esteja ocorrendo, o que de fato se verificou, pois apreendida grande quantidade de droga naquele local.

Assim, não há nulidade das provas daí decorrentes, seja pela existência de situação de flagrante, seja pela autorização do morador para entrada dos agentes públicos na residência.

Não houve prova concreta, entretanto, a respeito da prática do crime de associação criminosa previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, pois em momento algum foi evidenciado o animus associativo, relativo à finalidade de praticar, reiteradamente, o crime mencionado no artigo 33, caput, da mesma Lei, tampouco a permanência na *societas criminis*, a qual não se confunde com a mera coautoria. Acrescento o entendimento dos Tribunais:

O crime consuma-se com a simples associação previamente organizada, de caráter estável e permanente, independentemente de qualquer outro fato que venha a ser cometido pelos agentes. Desde que a associação delituosa, já caracterizada, alcança seu fim consistente na prática de crimes, lesa nova objetividade jurídica, possibilitando o concurso de delitos (STJ, REsp 3.943/SP, 5ª T., rel. Min. Flaquer

Scartezzini, . 26-9-1990, DJ 5-11-1990, JSTJ 20/45).

O delito previsto no art. 35, da nova lei, pressupõe, para o seu reconhecimento, a demonstração do dolo de associar-se de forma estável. É necessário que se identifique, na *societas criminis*, o caráter permanente, que não se confunde com a mera coautoria (TJMG – Ap. Crim. 1.0145.08.435450-8/001, 5ª Câmara Criminal, rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 24/03/2009).

É possível que os acusados tenham cometido tal crime, no entanto, as provas amealhadas aos autos não são suficientes para um decreto condenatório, porque inexistem elementos concretos a respeito da estabilidade do vínculo entre eles.

Mas, como se verá mais adiante, embora não provado o vínculo associativo entre os agentes, isto é, o dolo de associar-se de forma estável, é possível afirmar, com segurança, que eles se dedicavam à atividade criminosa, de modo a afastar a incidência da causa especial de diminuição de pena.

Reconhecida a ação criminosa, passo à fixação da pena (sistema trifásico: art. 68, caput, do CP).

Primeira fase: sopesadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, de natureza subjetiva (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente) e objetiva (motivos, circunstâncias e consequências do crime), com a preponderância do artigo 42 da Lei de Drogas, anote-se não existirem elementos que justifiquem a majoração da pena-base.

A diversidade e a quantidade da droga serão levadas em consideração na terceira fase de aplicação da pena, para evitar *bis in idem*. Nesse sentido: A controvérsia destes autos foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal em recente julgamento realizado pelo Plenário, ocorrido em 19/12/2013, na análise dos HC 112.776/MS e HC 109.193/MS, ambos de relatoria do Min. Teori Zavascki. Naquela oportunidade, esta Corte firmou o entendimento de que as circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas apreendidas em poder de um réu condenado por tráfico de entorpecentes apenas podem ser utilizadas, na primeira ou na terceira fase da dosimetria da pena, sempre de forma não cumulativa. Ressaltou-se, que a utilização em duas fases do cálculo da pena caracteriza o *bis in idem*, bem como autorizou a análise monocrática dos pedidos de habeas corpus que tratem sobre o tema. Desse modo, cabe ao juiz sentenciante, de acordo com seu poder discricionário, definir em qual momento da dosimetria da pena a circunstância referente a quantidade e a natureza da droga será utilizada, desde que não seja de maneira cumulativa para evitar-se a ocorrência de *bis in idem* (STF – RHC/MC nº 122.496/RS, Relator: Min. Luiz Fux. Data de julgamento: 22/08/2014 – grifos meus).

A condenação anterior do réu Samuel (autos nº 0000088-41.2017.8.26.0552) foi anulada em razão de decisão proferida em sede de Habeas Corpus, conforme consulta realizada àqueles autos digitais, de tal forma que não serve de fundamento apto à exasperação nesta ação penal, seja a título de maus antecedentes ou reincidência. Assim, fixo a pena-base dos réus no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda fase (arts. 61, 62 e 65, CP): não há agravantes a serem consideradas e nem atenuantes, a despeito da confissão de Lucas e Camila, porque incide o óbice da súmula 231 do STJ.

Terceira fase: nesta última etapa de fixação da pena, deixo de reconhecer a incidência do disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, porque embora os réus sejam primários e não ostentem maus antecedentes, está comprovado que se dedicavam à atividade criminosa.

Como já se observou, eles foram presos numa casa preparando drogas. Samuel convidou Lucas para preparar os entorpecentes na casa de Camila. Apreendeu-se mais de cinco centenas de porções de cocaína, já devidamente preparadas. Havia ainda cocaína "a granel", um liquidificador com resquícios de cocaína, 220 cápsulas vazias, balança de precisão e dois pratos com resquícios de cocaína. Outrossim, na casa de Lucas foi apreendida a quantia de R\$ 2.475,00 produto do narcotráfico, conforme revelado pela prova dos autos.

Conforme leciona Renato Marcão, a apreensão de expressiva quantidade de droga configura indicativo de que o agente é integrante de organização criminosa. A grande quantidade e variedade da droga, a propósito, atenta com maior intensidade

contra o bem jurídico tutelado, porquanto inegável a relevância de seu acentuado potencial lesivo, e faz desaconselhar o reconhecimento do "tráfico privilegiado". (Tóxicos. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 138).

E, no mesmo sentido, confirmam-se os seguintes julgados:

A quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas são critérios que evidenciam a dedicação a atividades criminosas, justificando o não reconhecimento do tráfico em sua forma privilegiada (STJ, AgRg no HC 615.796/CE, 5ª T., rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 20-10-2020, DJe de 22-10-2020).

Esta Corte tem reiterada orientação de que a quantidade e a natureza da droga, associadas ao contexto em que se deu a sua apreensão, podem evidenciar a dedicação à atividade criminosa (STJ, AgRg no HC 604.754/SP, 6ª T., rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 22-9-2020, DJe de 28-9-2020).

Assim, dentro desse contexto particular, constata-se que não se trata de traficantes ocasionais, mas sim de pessoas que se dedicavam ao narcotráfico e disseminação de drogas em massa nesta cidade. Não merecem o reconhecimento da minorante justamente porque não são aqueles chamados "pequenos" traficantes ou que se aventuraram pela primeira vez em empreitada delituosa desse tipo. Não fazem jus ao tráfico privilegiado.

Pena definitiva: 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

O dia multa é fixado no mínimo legal, considerando-se a condição econômica do acusado.

Regime inicial de cumprimento (art. 33, §§ 2º e 3º c/c art. 59, III, CP, e art. 387, § 2º, CPP): o regime de cumprimento será inicialmente o fechado para todos os réus porque, a despeito do quantum da pena, deve ser considerada a natureza do crime, equiparado a hediondo, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, isto à luz das particularidades do caso concreto.

As circunstâncias em que o crime foi praticado, observados os fatores subsidiados pelo art. 59 do Código Penal (embora não suficientes o bastante para fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo ou legal), desaconselham a imposição de regime mais brando, que seria insuficiente para reprovação do delito.

Relembre-se que: nos crimes de tráfico de entorpecentes, a escolha do regime prisional inicial deve levar em consideração a quantidade da pena imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e as demais peculiaridades do caso concreto (como a natureza e a quantidade de drogas apreendidas, por exemplo), para que, então, seja escolhido o regime carcerário que, à luz do disposto no art. 33 e parágrafos do Código Penal, se mostre o mais adequado para a prevenção e a repressão do delito perpetrado (AgRg no HC nº 322.686/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/08/2015, DJe 11/09/2015).

De fato, as provas dos autos revelaram, além da dedicação reiterada ao tráfico, que os réus estavam preparando drogas numa casa, apreendendo-se grande quantidade conforme afirmado anteriormente.

Assim, é certo que os acusados estavam disseminando de forma mais danosa o vício, razão pela qual a concessão dos benefícios pleiteados não faria atender à suficiência quanto à reprovação de sua nefasta conduta, mesmo que não ostentem antecedentes.

E, para além das circunstâncias do caso concreto, já delineadas, cumpre observar que, nesta Comarca, vem subindo consideravelmente o número de ocorrências relativas ao tráfico de entorpecentes, seja com maiores de idade, seja com adolescentes e até mesmo crianças, abalando sensivelmente a sociedade, que aguarda resposta estatal mais condizente com as peculiaridades locais.

Impõe-se o regime fechado aos acusados ainda que levado em conta o tempo de prisão provisória e a disposição do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal. Isso porque, esta regime mais gravoso foi adotado em razão das particularidades do caso em apreço, não se observando, apenas e tão somente, a expressão aritmética das reprimendas.

Esclareça-se que o tempo de prisão provisória não necessariamente repercutirá na fixação de regime menos gravoso, pois a escolha deste sujeita-se a diversos

critérios, em especial as circunstâncias do fato em julgamento, conforme subsídio do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Esta é a lição de Renato Marcão: Ao impor condenação, o juiz deverá verificar se na hipótese é cabível e, sendo caso, operar o abatimento do tempo de prisão ou internação já cumprido. Tal redução irá repercutir não apenas no tempo de pena a cumprir (pena restante), mas eventualmente na fixação do regime inicial de cumprimento da privativa de liberdade, observados os parâmetros ditados pelo art. 33 do Código Penal, onde há critérios quantitativos para escolha do regime. Cabe observar que o critério quantitativo da pena não é o único a ser considerado na fixação do regime prisional, daí não ser acertado concluir que a detração sempre irá repercutir no regime a ser fixado na sentença. Não se desconhece a possibilidade de cumprimento de pena privativa de liberdade inferior a 8 (oito) anos no regime fechado. De igual maneira, a pena inferior a 4 (quatro) anos também poderá ser cumprida em regime semiaberto e eventualmente no fechado, tal como decorre do disposto no § 3º do art. 33, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.

(Curso de Processo Penal. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2021, p. 402).

É por isso que, considerada a situação pessoal dos acusados e as circunstâncias em que ocorreram os crimes, mesmo considerado o tempo de prisão provisória, mantém-se a imposição do regime fechado.

Por fim, os réus deverão permanecer na prisão, para a garantia da ordem pública, ante a natureza dos delitos e à vista de todo o exposto, especialmente das considerações quanto à fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena e não substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, notadamente neste momento, com prolação de sentença condenatória, mantidos os demais fundamentos que embasaram a decretação da prisão cautelar.

Ante o exposto:

(i) absolvo CAMILA DE OLIVEIRA, LUCAS DE JESUS DA ROCHA e SAMUEL SOUZA FERREIRA, qualificados nos autos, de terem praticado o crime previsto no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

(ii) condeno CAMILA DE OLIVEIRA, LUCAS DE JESUS DA ROCHA e SAMUEL SOUZA FERREIRA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c.c. artigo 29 do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no piso legal mínimo.

Tendo respondido ao processo em prisão cautelar, e como não houve alteração no panorama probatório que ensejou tal fato – aliás, a sentença reconheceu a responsabilidade criminal -, denega-se o direito de recorrer(em) em liberdade, subsistentes os pressupostos e os requisitos da prisão preventiva (art. 312 c/c art. 313, CPP) nos termos do que foi decidido anteriormente neste processo.

Recomendem-se nas prisões em que se encontram.

Decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos, em favor da União, com posterior reversão ao Funad, após o trânsito em julgado, na forma do artigo 63 e §§ da Lei nº 11.343/2006.

Fica também autorizada a incineração do entorpecente, caso ainda não procedida.

Os acusados pagarão a taxa judiciária, ressalvado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicado por analogia, em razão de sua hipossuficiência e da gratuidade.

Após o trânsito em julgado: a) Comunique-se o Instituto de Identificação (IIRGD); b) oficie-se ao TRE para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição da República de 1988; c) expeça-se guia de execução definitiva ou oficie-se para aditamento da guia de recolhimento provisória, remetendo-se ao juízo competente; d) intime-se o réu para pagamento da multa, no prazo de 10 (dez) dias e da taxa judiciária, se o caso, em 60 (sessenta) dias, procedendo-se na forma dos artigos 480 e 480-A das NSCGJ.

Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se.

Publique-se e intímem-se.

Leme, 24 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA